

1500080-79.2021.8.26.0574
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: FLÁVIA SNAIDER RIBEIRO
Comarca: Paranapanema
Foro: Foro de Paranapanema
Vara: Vara Única
Data de Disponibilização: 15/01/2022
... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
AILTON RODRIGUES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FLÁVIA SNAIDER RIBEIRO

Vistos.

I - RELATÓRIO

Trata-se de Ação Penal Pública Incondicionada proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em face de AILTON RODRIGUES, qualificado nos autos, em razão da suposta ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Paranapanema
Foro de Paranapanema
Vara Única
Rua Dr. Fortunato Martins de Camargo, Paranapanema - SP - cep 18720-000

1500080-79.2021.8.26.0574 - lauda
SENTENÇA

Processo nº:
1500080-79.2021.8.26.0574
Classe - Assunto
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
AILTON RODRIGUES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FLÁVIA SNAIDER RIBEIRO

Vistos.

I - RELATÓRIO

Trata-se de Ação Penal Pública Incondicionada proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em face de AILTON RODRIGUES, qualificado nos autos, em razão da

suposta prática do delito capitulado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Segundo consta da Denúncia (fls. 148/150), na data de 19 de março de 2021, por volta das 19 horas, na Rua Urias Domingues Leite, nº 360, nesta cidade e comarca de Paranapanema, AILTON RODRIGUES tinha em depósito 36 (trinta e seis) porções de cocaína, na forma de crack, com peso bruto de 19,3g (dezenove gramas e três decigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para entrega ao consumo de terceiros.

Acompanharam os autos deste processo o inquérito policial, no qual foram encadernadas, dentre outras, as seguintes peças: auto de prisão em flagrante (fl. 01), boletim de ocorrência (fls. 02/05), termos de declarações (fls. 06/08 e 15), auto de exibição e apreensão (fls. 11/12) e auto de constatação preliminar de substância entorpecente (fl. 14), além do relatório lavrado pela Autoridade Policial (fls. 146/147).

A prisão em flagrante foi homologada e convertida em prisão preventiva pela decisão de fls. 118/121.

Notificado, o Réu apresentou Defesa Prévia às fls. 180/187, através de Defensor Dativo.

Porquanto preenchidos os requisitos legais, a Denúncia foi recebida em 09 de agosto de 2021 e, não se verificando nenhuma hipótese de rejeição ou absolvição sumária, designou-se Audiência de Instrução, Debates e Julgamento (fls. 194/197).

Decisão de fls. 214/216 rejeitou as preliminares arguidas pela Defesa Técnica.

Às fls. 225/228, foi juntado o laudo definitivo de exame químico-toxicológico.

Realizada Audiência de Instrução e Julgamento, cindida em dois dias, as testemunhas foram ouvidas (fls. 254/255), foi procedida à acareação requerida pela Defesa Técnica e, por fim, o Réu foi interrogado (fls. 300/301).

Sobrevieram as alegações finais do Ministério Público, em resumo, pleiteando a condenação do acusado nos termos da Denúncia. A Defesa Técnica, por sua vez, arguiu, preliminarmente, a nulidade processual, ante a ilegalidade da ação policial que culminou na prisão em flagrante do Réu. No mérito, pugnou, em síntese, pela absolvição do acusado ou subsidiariamente, pela desclassificação do delito para o previsto no art. 28, caput, da Lei nº 11.343/06 ou, ainda, pelo reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, com a fixação do regime aberto para início do cumprimento da pena privativa de liberdade (fls. 304/320).

Vieram os autos conclusos para sentença.

É o relatório, no essencial. Passo a fundamentar e a decidir.

II - FUNDAMENTAÇÃO

A Defesa Técnica arguiu, a título de preliminar, a ilicitude das provas obtidas na residência do acusado, sob o argumento de que houve indevida violação de seu domicílio pelos policiais militares.
Pois bem.

Primeiramente, há que se ressaltar que, como cediço, a Constituição da República autoriza a violação ao domicílio nos casos de flagrante delito, seja durante o dia, seja durante a noite, e independentemente de prévia autorização judicial. Nos termos do inciso XI do art. 5º da Carta Magna, “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em

caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”.

No caso concreto, ainda que se discuta acerca da existência de consentimento válido do(s) morador(es), o ingresso na residência do acusado, na verdade, decorreu de ligação recebida pela Polícia Militar, por pessoa não identificada, noticiando que o Réu estaria agredindo fisicamente sua ex-companheira, Sra. Eliane de Fátima Pereira, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher; isto é, no sentido de que, no interior da residência do acusado, estaria ocorrendo um delito, naquele exato momento. Tal circunstância não apenas autoriza, de acordo com a previsão constitucional, o ingresso forçado na residência, como também justifica a prisão pré-cautelar daquele que está em flagrante delito, com base no que dispõe o art. 302, inciso I, do Código de Processo Penal, como ocorreu no caso concreto.

A doutrina especializada destaca que “[o] próprio Código Penal, em seu art. 150, § 3º, inciso II, dispõe que não constitui crime de violação de domicílio a entrada ou permanência em casa alheia ou em suas dependências a qualquer hora do dia ou da noite, quando algum crime está sendo ali praticado ou na iminência de o ser. Nesses casos, para que a polícia possa adentrar em uma residência, sem mandado judicial, exige-se aquilo que costuma chamar de 'causa provável' (no direito norte-americano, probable cause), ou seja, quando os fatos e as circunstâncias permitiriam a uma pessoa razoável acreditar ou ao menos suspeitar, com elementos concretos, que um crime está sendo cometido no interior da residência. Aliás, em recente julgado, o Supremo admitiu que não há ilegalidade na prisão em flagrante realizada por autoridade policial baseando-se em notícia anônima. (...) Em síntese, o modelo probatório deve ser o mesmo da busca e apreensão domiciliar, que pressupõe a presença de fundadas razões (CPP, art. 240, § 1º), as quais, logicamente, devem ser exigidas de maneira modesta e compatível com o momento em questão”.

No caso em apreço, conforme já assinalado, encontram-se devidamente demonstradas as “fundadas razões”, sobretudo diante do teor dos depoimentos dos policiais militares.

Com efeito, conforme relatado pelos agentes públicos que realizaram a prisão em flagrante do acusado, na data dos fatos, a equipe foi acionada em razão de suposta desinteligência ocorrida entre o Réu e sua ex-companheira, no interior da residência do primeiro. Ao chegarem ao local dos fatos, os agentes da lei foram chamados pela Sra. Eliane, que pediu ajuda, ocasião em que o acusado foi inicialmente abordado – ainda fora da residência –, tendo aquela, então, afirmado que o Réu havia tentado agredi-la fazendo uso de uma faca. A situação de possível violência doméstica contra a mulher e este último fato – utilização de uma faca – motivaram o ingresso dos policiais militares no interior da residência, para busca domiciliar, ocasião em que, de forma inevitável e fortuita, encontraram os entorpecentes embalados sobre a mesa da cozinha.

Ora, o fato de os policiais militares atenderem ocorrência de violência doméstica e familiar contra a mulher, praticada no interior da residência do acusado, no entender deste Juízo, constitui-se razão bastante a justificar a violação do domicílio sem prévia autorização judicial, já que se revelava evidente situação de flagrante delito.

Vale anotar, sob outro aspecto, que a despeito das alegações do Réu, nada de concreto afasta a credibilidade dos depoimentos dos policiais militares, agentes públicos que, segundo o que consta dos autos, não mantinham inimizade ou qualquer tipo de desentendimento prévio com o acusado.

Por fim, há que se ressaltar, e apenas a título de complementação, que, no caso do delito de tráfico de drogas, eventual ausência de consentimento para ingresso na residência não gera nulidade, uma vez que o referido crime, notadamente nas

modalidades “guardar” e “ter em depósito”, possui natureza permanente, autorizando a prisão em flagrante, bem como o ingresso em domicílio, mesmo sem ordem judicial prévia ou autorização do morador (CPP, art. 303 c/c CRFB, art. 5º, inciso XI). Nesse sentido, aliás, é o entendimento do c. Supremo Tribunal Federal firmado em sede de Recurso Extraordinário, com Repercussão Geral reconhecida:

“Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protraí no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso”.

(RE 603616, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-093 DIVULG 09-05-2016 PUBLIC 10-05-2016)

Não é outro o entendimento do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico ilícito de drogas – Artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Palavra dos policiais militares – Credibilidade – Precedentes – Destinação mercantilista do entorpecente apreendido evidenciada pelas circunstâncias fáticas da prisão – Nulidade decorrente da invasão de domicílio – Não cabimento – Em se tratando de crime de tráfico ilícito de drogas, delito de natureza permanente, a ausência de mandado não macula a busca e apreensão – Condenação mantida – Dosimetria penal – Reprimenda aplicada de forma adequada – Aplicação do redutor – Impossibilidade – Circunstâncias do caso concreto que indicam que o acusado se dedicava a atividades criminosas, no caso, ao tráfico habitual de drogas, bem como ostentava maus antecedentes – Substituição da sanção carcerária por penas restritivas de direito – Descabimento – Ante a natureza e quantidade dos entorpecentes apreendidos a substituição da sanção carcerária por penas restritivas de direitos não se mostra suficiente no caso concreto – Regime fechado – Adequado à espécie – RECURSO NÃO PROVIDO”.

(TJSP; Apelação Criminal 0000406-43.2018.8.26.0599; Relator (a): Silmar Fernandes;

Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Piracicaba - 4ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 03/10/2019; Data de Registro: 04/10/2019)

Ante o exposto, REJEITO a preliminar arguida pela Defesa e, por consectário lógico, considero lícitas todas as provas colhidas durante a realização das diligências de busca e apreensão domiciliar, bem como as que delas são derivadas.

Presentes as condições da ação e não havendo outras preliminares e/ou prejudiciais a serem dirimidas, passo à análise do mérito.

A materialidade do crime corresponde à prova de sua existência; em outras palavras, são os elementos que demonstram a ocorrência/existência do delito. Na situação sob julgamento, a materialidade delitiva do crime de tráfico de drogas restou devidamente comprovada através do auto de prisão em flagrante de fl. 01, do boletim de ocorrência de fls. 02/05, do auto de exibição e apreensão de fls. 11/12, do auto de constatação preliminar de substância entorpecente de fl. 14 e do laudo definitivo de exame químico-toxicológico de fls. 225/228 – no qual fora detectada a presença da substância cocaína.

Do mesmo modo que a materialidade, a autoria encontra-se devidamente comprovada nos autos, já que o conjunto probatório demonstra, além de qualquer dúvida razoável, que o acusado AILTON RODRIGUES foi o autor do crime de tráfico de drogas narrado na Denúncia, conforme será devidamente demonstrado a seguir.

Com efeito, as provas colhidas durante a instrução processual são bastantes a fundamentar um juízo condenatório.

Em seu primeiro depoimento em juízo, a testemunha Eliane de Fátima Pereira relatou que, na data dos fatos, foi chamada pelo acusado para limpar a residência dele; que, em dado momento, o acusado perguntou se ela gostaria de tomar cerveja, sendo que passaram a beber na rua; que, assim que retornaram para a casa, a Polícia chegou; que não tinha conhecimento acerca da existência das drogas; que não tinha conhecimento de que o acusado usava drogas (cocaína e maconha); que não sabe dizer se o acusado estava trabalhando; que sabe que o acusado estava desempregado; que não estavam morando juntos; que as drogas foram achadas em cima da mesa, dentro de uma maço de cigarro; que observou o momento em que os policiais localizaram as drogas; que o acusado residia sozinho, sendo ajudado financeiramente pela filha; que nunca viu o Réu usar crack; que acredita que os policiais militares foram chamados pela vizinha, não sabendo quem os autorizou a entrar na residência; que os policiais foram chamados porque o acusado teria lhe desferido um murro e a ameaçado com uma faca; que, na data dos fatos, não estavam mais juntos, mas ocasionalmente se relacionava com o acusado; que estava com o Réu na "área" da casa no momento em que os policiais chegaram; que, quando a polícia chegou, o acusado jogou a faca dentro do tanque; que os policiais viram o acusado com a faca na mão, bem como o momento em que a jogou no tanque; que os policiais entraram na residência para procurar a faca.

Por sua vez, por ocasião da acareação realizada em juízo, a testemunha relatou que não sabe dizer quem chamou a polícia; que, no momento em que percebeu, os policiais já estavam no portão da casa, momento em que foi ao encontro deles; que os policiais entraram na residência com ela; que não abriu o portão; que relatou aos policiais que teria sido agredida; que acredita que a polícia foi chamada pela vizinha porque havia dado um grito anteriormente; que os policiais já estavam dentro da casa e que não chamou por ajuda; que estava na "área" da residência, ocasião em que o acusado a chamou para entrar na casa; que, no interior da casa, o acusado teria lhe desferido um soco e "puxado" uma faca contra ela; que notou a Polícia chegar e pediu por socorro; que solicitou ajuda aos policiais na data dos fatos.

Por sua vez, a testemunha Thiago Amaral de Oliveira, policial militar, narrou, sob

compromisso legal, que, na data dos fatos, receberam um chamado para atendimento de ocorrência de violência doméstica; que, no local, havia um corredor e a casa aos fundos; que, assim que desembarcaram da viatura, a vítima veio em sua direção gritando e dizendo que o acusado teria a agredido e a ameaçado com uma faca; que realizaram a abordagem do acusado e não encontraram nada; que a revista pessoal foi feita no corredor; que a vítima afirmou novamente ter sofrido agressão e que a faca teria ficado no interior da casa; que, diante dessa circunstância, solicitaram autorização para ingresso na residência, o que foi consentido pela vítima; que a entrada da casa já dá acesso à cozinha, sendo que, em cima da mesa, estava um maço de cigarro contendo as porções de crack; que a faca não foi localizada no interior da residência; que, ao saírem da casa, acharam a faca dentro do tanque; que, em razão dos fatos, deram voz de prisão ao acusado e conduziram as partes à Delegacia; que não sabe dizer quem acionou a Polícia; que, no momento da abordagem, não presenciaram nenhuma agressão feita pelo Réu em face da vítima; que já abordou o Réu em outras ocasiões, em virtude de denúncias pela prática de tráfico; que, assim que pararam a viatura, a vítima já estava no corredor, vindo ao encontro gritando que havia sido agredida; que, na revista realizada, não foi encontrado nada com o acusado; que acredita que a faca foi dispensada no tanque no momento em que o acusado saiu da residência; que a entrada na residência foi autorizada pela vítima, para que pudessem procurar a faca; que o acusado assumiu a propriedade da droga; que, após a localização da substância entorpecente e da faca, procederam à nova abordagem no Réu, ocasião em que foi localizada a quantia de cento e oitenta e um reais em notas diversas; que o acusado não disse qual seria a fonte do dinheiro; que havia denúncias de moradores próximos no sentido de que o acusado praticava o tráfico de crack nesta urbe; que a entrada no imóvel foi feita logo após contato com a vítima e a abordagem do acusado; que tiveram contato com a vítima no portão da casa, sendo que foi ela quem autorizou a entrada na residência; que não se recorda se o portão já estava aberto ou se a vítima quem abriu.

Por ocasião da acareação procedida em juízo, a testemunha reiterou suas declarações anteriores. Relatou que foi acionado, na data dos fatos, para atendimento de ocorrência de violência doméstica; que, no local, havia um corredor e a casa aos fundos; que, assim que desembarcaram da viatura, a vítima foi ao seu encontro gritando por socorro porque o acusado estava vindo atrás com uma faca; que realizaram abordagem no acusado e não encontraram nada; que a revista foi feita no corredor; que a vítima insistiu que o acusado estava armado; que perguntou onde estaria a faca, tendo a vítima dito que o acusado poderia tê-la jogado "lá dentro"; que, em razão disso, pediram autorização para ingresso na residência, o que foi permitido pela vítima, uma vez que o acusado a estava ameaçando com a faca.

Indagada, Eliane concordou com a narrativa apresentada pela testemunha Thiago, confirmando ter autorizado o ingresso dos policiais na residência. Relatou, ainda, que os acompanhou e viu quando localizaram a faca dentro do tanque.

Por seu turno, também ouvida em juízo, a testemunha Sandro Henrique de Campos, policial militar, relatou, sob compromisso legal, que, na data dos fatos, receberam um chamado, via COPOM, para atendimento de ocorrência de violência doméstica; que, no local dos fatos, fizeram contato com a vítima, a qual os relatou que o Réu a teria agarrado pelo pescoço, desferido um soco e a ameaçado com uma faca; que, enquanto conversavam com a vítima, o acusado logo veio ao encontro; que realizaram revista pessoal no acusado e não localizaram a faca; que pediram autorização para ingresso na residência a fim de localizar a faca, o que foi autorizado pela vítima; que adentraram na residência e, em cima da mesa, encontraram um maço de cigarro contendo as trinta e seis porções de crack; que a faca foi localizada dentro do tanque; que voltaram e fizeram nova revista no acusado, ocasião em que localizaram a quantia de cento e oitenta e um reais em dinheiro, em notas diversas; que deram voz de prisão ao acusado e conduziram as partes à Delegacia; que não sabe dizer quem acionou a Polícia, mas acredita que tenha sido a própria vítima; que já houve outras ocorrências de desinteligência entre o casal; que, no momento em que

chegaram no local, a vítima foi ao encontro dos policiais, relatando ter sido agredida; que o acusado logo veio atrás; que havia denúncias quanto à prática de tráfico pelo acusado, sendo que a casa era bastante frequentada por usuários de drogas; que a casa do acusado localiza-se nas proximidades de um bar, que é frequentado por usuários de drogas, sendo que o acusado era visto constantemente no local; que, no momento em que chegaram, as partes estavam no interior do imóvel, tendo a vítima vindo ao encontro deles, seguida pelo acusado; que, ao chegarem para atendimento da ocorrência, ficaram do lado de fora do portão; que a vítima quem autorizou a entrada dos policiais na residência; que, no momento dos fatos, não prestaram atenção se havia algum usuário no local, sendo que o bar estava fechado.

Por ocasião da acareação procedida em juízo, a testemunha também reiterou suas declarações anteriores. Relatou que, na data dos fatos, foi acionado para atendimento a um chamado de violência doméstica; que, no local, pararam a viatura com o "highlight" ligado e, ao desembarcarem, a vítima veio ao encontro da guarnição, dizendo ter sido agredida com um soco e que o acusado estaria a ameaçando com uma faca; que a vítima abriu o portão; que procederam à revista pessoal no acusado a fim de localizar a faca, mas sem sucesso; que a vítima insistia que o acusado estava armado; que, diante do impasse, solicitaram autorização para ingresso na residência, o que foi consentido pela vítima, que inclusive os acompanhou; que encontraram os entorpecentes dentro de um maço de cigarros, em cima da mesa da cozinha.

Novamente indagada, Eliane concordou com o relato do policial Sandro. A Defesa, por sua vez, indagou as testemunhas a respeito de quem teria aberto o portão. Eliane, então, relatou que o portão já estava aberto, tendo encontrado com os policiais no corredor. A testemunha Thiago confirmou que o portão estava aberto, mas afirmou que fizeram contato com Eliane a partir do portão, e não da área da casa. A testemunha Sandro, por sua vez, afirmou que a vítima veio ao encontro dos policiais no portão da casa. Eliane, por fim, confirmou ter encontrado com os policiais militares na entrada do portão.

Por fim, interrogado em juízo, o Réu AILTON RODRIGUES relatou que, na data dos fatos, discutiu com Eliane e deu um empurrão nela; que chamaram a polícia, a qual achou as drogas em cima da mesa; que a revista pessoal foi feita no corredor da casa e que o portão estava fechado, porque tem o costume de trancá-lo; que não se recorda acerca da quantidade de droga que adquiriu, mas que se destinava a consumo próprio; que adquiriu a substância no município de Angatuba/SP; que é usuário, porém nunca vendeu drogas; que é usuário há bastante tempo, tendo pagado duzentos e quarenta reais pela droga; que, na época dos fatos, estava desempregado e trabalhava como diarista; que foi abordado no corredor que dá para sua residência, sendo que os policiais foram até Eliane; que não autorizou os policiais militares a entrarem na residência; que a casa não pertencia à Eliane.

Primeiramente, no que tange ao depoimento de policiais militares, ressalta-se não existir dispositivo legal vedando ao agente público servir como testemunha. Além disso, não se acredita que servidores públicos, inclusive os milicianos, empossados que são após compromisso de fielmente cumprirem seus deveres, apresentariam testemunhos ou provas ideologicamente falsas, com o simples intuito de inculpar inocentes. Ao contrário, têm os funcionários públicos a presunção de que, no desempenho de suas atuações, agem escorreitamente.

Importante ressaltar que o policial é testemunha como outra qualquer, já que não figura entre os impedidos ou suspeitos, sujeitando-se ao compromisso de dizer apenas a verdade, sob as penas do falso testemunho. Ademais, nos casos de tráfico de drogas, nos quais o testemunho civil é quase sempre impossível, deve ser conferido às declarações do policial o merecido valor em confronto com os demais elementos de convicção trazidos aos autos.

Nessa linha de raciocínio, já decidiu o c. Supremo Tribunal Federal que “o valor do depoimento testemunhal de servidores públicos especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal” (HC nº 74.608-0/SP, rel. Min. Celso de Mello).

O c. Superior Tribunal de Justiça, da mesma forma, entende que “o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal” (HC 236.105/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma).

No caso em apreço, os policiais militares que participaram da diligência que culminou na prisão em flagrante do Réu narraram, tanto em solo policial quanto em juízo, de forma harmônica e coerente, o envolvimento do acusado com a traficância, como pode ser observado dos depoimentos acostados às fls. 06/07 e dos anteriormente transcritos.

Ademais, as circunstâncias do encontro das substâncias entorpecentes, além do que já se expôs, geram a convicção da posse voltada para o comércio e não a finalidade para o uso próprio, diferentemente do que afirmou o acusado em juízo e sua Defesa Técnica, em versão totalmente isolada dos demais elementos probatórios coligidos aos autos.

Anote-se que a relevante quantidade de porções de droga encontrada na residência de AILTON – 36 (trinta e seis) porções de cocaína, na forma de crack, com peso bruto de 19,3g (dezenove gramas e três decigramas) - fls. 225/228 –, sobretudo considerando a região em que o crime foi cometido (pequena cidade do interior) e comparando-se com as apreensões da mesma droga comumente nela realizadas, indica a destinação para o tráfico, assim como as circunstâncias do encontro das substâncias entorpecentes – concomitante ao encontro de dinheiro em espécie, em notas variadas, estando a droga embalada de forma e em quantidade uniformes, para pronta venda, e após diversas “denúncias anônimas” de populares no sentido de que o acusado vinha traficando drogas na cidade –, além do que já se expôs, geram a convicção da posse voltada para o comércio e não (apenas) a finalidade para o uso próprio.

Ainda, em consonância com a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a caracterização do crime de tráfico de drogas prescinde que o Réu seja surpreendido no momento da realização da mercancia da droga, especialmente porque o tipo penal é misto alternativo e a prática de qualquer conduta do núcleo do tipo caracteriza o delito. Nesse sentido, conforme trecho do v. acórdão proferido na Apelação nº 0000926-20.2016.8.26.0616, “[p]or outro lado, o crime de tráfico de entorpecentes é de perigo abstrato, punindo-se a conduta pelo risco que ele representa para a saúde pública, de modo que não há necessidade de efetiva prática de ato de comércio, bastando que o agente seja apanhado trazendo consigo, guardando ou mantendo em depósito substância entorpecente com finalidade de venda” (TJSP; Apelação 0000926-20.2016.8.26.0616; Relator (a): Airton Vieira; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itaquaquetuba - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 31/07/2018; Data de Registro: 03/08/2018).

À vista de todos esses elementos, conclui-se que o Réu AILTON RODRIGUES, com consciência e vontade, isto é, agindo dolosamente, praticou os fatos descritos na Denúncia, conduta esta que se amolda formal e materialmente ao tipo do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Conforme a Teoria da Indiciarietade ou da Ratio Cognoscendi, acolhida pela doutrina majoritária e pela legislação processual, a tipicidade funciona com um indício da ilicitude, razão pela qual cabe ao Réu trazer aos autos ao mesmo a

dúvida fundada quanto à presença de uma causa de justificação, nos termos do art. 386, inciso VI, do Código de Processo Penal.

No caso sob julgamento, contudo, o Réu sequer alegou a existência de causas excludentes da ilicitude. Além disso, inexistem nos autos qualquer elemento que aponte que ele agiu de forma justificada. Assim, sendo a tipicidade indiciária da ilicitude e não havendo causas excludentes desta, configurado está o injusto penal.

Quanto à culpabilidade, esta analisada à luz da Teoria Normativa Pura, de viés finalista, como reprovabilidade do injusto ao autor, composta dos elementos imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa, do mesmo modo, inexistem nos autos qualquer elemento que possa afastá-la. Destaco que o Réu sequer suscitou a existência de dirimentes. Desse modo, tem-se que a culpabilidade está presente, porquanto o Réu é imputável e dotado de potencial consciência da ilicitude, bem como lhe era exigível conduta diversa.

Assim, comprovadas a materialidade, a autoria, a tipicidade e inexistindo causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, impõe-se a condenação do Réu AILTON RODRIGUES pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Por fim, verifica-se a impossibilidade da incidência da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 no caso em apreço, sendo certo que o benefício legal deve prestigiar apenas os chamados “pequenos traficantes”, devendo, portanto, seus requisitos legais serem interpretados de forma restritiva.

Quanto ao acusado AILTON, a incidência da causa benéfica legal não se revela concretamente possível diante da comprovação de que vem se dedicando a atividades criminosas, já que, além de ser reincidente e portador de maus antecedentes (autos nº 0001975-41.2007.8.260025, 0000253-82.2006.8.26.0420, 0000331-32.2013.8.26.0420 e 1502470-04.2018.8.26.0420 – fls. 289/293), foi encontrado na posse de relevante quantidade de entorpecentes, acondicionados de maneira uniforme, para pronta venda, circunstâncias que revelam que o acusado vinha fazendo da traficância seu meio de vida.

Fixadas tais premissas, passo à dosimetria da pena, em estrita observância ao princípio constitucional da individualização da pena (CF, art. 5º, inciso XLVI), bem como do critério trifásico adotado pelo Código Penal (art. 68).

Das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e do artigo 42 da Lei nº 11.343/06: a) Culpabilidade: cuida esta circunstância judicial do grau de reprovabilidade da conduta do agente, ou censurabilidade do delito cometido. No caso em apreço, é inerente ao tipo penal; b) Antecedentes: trata-se de acusado com antecedentes criminais, tendo em vista que possui quatro condenações criminais transitadas em julgado em seu desfavor (autos nº 0001975-41.2007.8.260025, 0000253-82.2006.8.26.0420, 0000331-32.2013.8.26.0420 e 1502470-04.2018.8.26.0420 – fls. 289/293), sendo certo, no entanto, que apenas as três primeiras serão valoradas nesta fase da dosimetria da pena e, a última, na fase subsequente, considerando o que determina o Enunciado de Súmula nº 241 do c. Superior Tribunal de Justiça; c) Conduta social: não há nos autos elementos suficientes para avaliar a vida do acusado em seu ambiente familiar e social, razão pela qual a circunstância não pode ser valorada negativamente; d) Personalidade do agente: não há elementos nos autos que permitam avaliar a personalidade do Réu, razão pela qual também não se pode valorá-la negativamente; e) Motivos do crime: os motivos do crime são aqueles inerentes ao tipo; f) Circunstâncias do crime: as circunstâncias em que o crime foi praticado não excedem o que se espera em condições normais; g) Consequências do crime: do mesmo modo as consequências, que são aquelas que se devem ordinariamente esperar do crime em questão; h) Comportamento da vítima: trata-se de crime sem vítima determinada, motivo pelo qual tal circunstância será valorada como neutra; i) Natureza e quantidade da droga: não devem ser valoradas negativamente, pois não extrapolam o ordinário à espécie. Assim, diante de tais circunstâncias, elevo a

pena mínima cominada e fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, reconheço a agravante da reincidência (CP, art. 61, inciso I), considerando a condenação definitiva do Réu nos autos nº 1502470-04.2018.8.26.0420 – trânsito em julgado em 23.02.2021, conforme informação de fl. 292. Por outro lado, não há circunstâncias atenuantes a serem consideradas, devendo ser ressaltados os termos do Enunciado de Súmula nº 630 do c. Superior Tribunal de Justiça: “A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio”. Nesse sentido, elevo a pena-base em 1/6 (um sexto) e fixo a pena intermediária em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou de diminuição de pena a serem valoradas, razão pela qual fixo a pena definitiva em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Em atendimento ao disposto no art. 49, § 1º, do Código Penal, fixo valor do dia-multa em 1/30 do maior salário-mínimo vigente à época dos fatos, pois não há nos autos informações sobre a condição financeira do Réu.

Considerando que o tempo de prisão provisória não alteraria o regime prisional, deixo de realizar a detração (CPP, art. 387).

Impede salientar, por fim, que o c. Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado no sentido de que são inconstitucionais as previsões da Lei nº 11.343/06 que impõem a adoção obrigatória do regime inicial fechado e a vedação da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, devendo serem observadas as regras do Código Penal quanto ao ponto.

Por outro lado, nada impede a fixação de regime inicial fechado, diante da gravidade em concreto da conduta criminosa. A propósito:

“APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. Sentença condenatória. Recurso defensivo. Materialidade e autoria devidamente comprovadas pelo conjunto probatório carreado aos autos. O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais, especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória. Dosimetria que não comporta reparo. Regime inicial fechado adequadamente imposto, diante da gravidade em concreto da conduta, aliada à reincidência. Inviabilidade de substituição da pena privativa de liberdade. Dias-multa. Inconstitucionalidade. Não reconhecimento. RECURSO DESPROVIDO”.

(TJSP; Apelação 0016111-79.2018.8.26.0050; Relator (a): Camargo Aranha Filho; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 7ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 04/02/2019; Data de Registro: 04/02/2019)

Na situação ora em apreço impõe-se a adoção do regime inicial fechado, notadamente diante da relevante quantidade de drogas apreendidas – notadamente considerando a região em que realizada a apreensão –, da reincidência e dos maus antecedentes do Réu. Desta feita, nos termos dos art. 33, §§ 2º e 3º do Código Penal, levando em consideração a pena e as circunstâncias judiciais do artigo 59 do mesmo diploma legal, fixo o regime FECHADO para o início do cumprimento da pena.

Diante da quantidade de pena aplicada, incabíveis a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, art. 44) e a suspensão condicional da pena (CP, art. 77).

IV - DISPOSITIVO

Ante o exposto JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva veiculada na Denúncia para condenar o Réu AILTON RODRIGUES, qualificado nos autos, pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, às penas de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, fixados no valor unitário mínimo legal.

V - DISPOSIÇÕES FINAIS

V.I. CONDENO o sentenciado ao pagamento das custas processuais (CPP, art. 804).

V.II. Conforme determinação do art. 387, §1º, do Código de Processo Penal, diante da subsistência dos motivos já expostos nas decisões anteriores (fls. 118/121, 167/169, 214/216 e 302/303) e por entender presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, mantenho a prisão preventiva anteriormente decretada. Com efeito, o fumus comissi delicti decorre da própria procedência da pretensão punitiva veiculada na Denúncia, havendo prova da materialidade e indícios de autoria do crime atribuído ao Réu. O periculum libertatis, por sua vez, é evidenciado pela gravidade em concreto do delito perpetrado pelo Réu, da possibilidade concreta de voltar a delinquir, considerando a reincidência e os maus antecedentes, bem como da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que não existem garantias de que, em liberdade, não se afastará do distrito da culpa.

V.II.I. EXPEÇA-SE guia de execução provisória.

V.II.II. Além disso, ANOTE-SE a revisão da prisão no sistema SAJ, notadamente para futura reapreciação, devendo a Serventia observar o disposto no COMUNICADO CG nº 78/2020.

V.III. Considerando a demonstração de que o numerário apreendido é produto do crime de tráfico de drogas, com fundamento no art. 91, inciso II, alínea "b", do Código Penal c/c art. 63, inciso I, da Lei nº 11.343/06, como efeito secundário da condenação, DECRETO o perdimento em favor da União dos valores apreendidos às fls. 11/12. Com o trânsito em julgado da presente sentença, PROCEDA-SE a reversão da quantia em favor do FUNAD.

V.IV. DEIXO DE ARBITRAR o valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, previsto no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, diante da ausência de pedido expresso acerca do montante a ser ressarcido, bem como, por consequência, da ausência de contraditório acerca da matéria.

V.V. COMUNIQUE-SE a condenação ao IIRGD (art. 393, V, das NSCGJ) e, com o trânsito em julgado, intime-se o Réu para pagamento das custas judiciais (art. 479, das NSGCJ). Infrutífera a intimação ou não efetuado o pagamento no prazo assinalado, EXPEÇA-SE Certidão de Sentença, extraída na forma do artigo 164 da Lei nº 7.210/84 e artigos 479-B e 480-A das NSCGJ. Expedida a Certidão, DÊ-SE VISTA ao Ministério Público, para que, querendo, proponha a competente ação de execução da pena de multa na Vara das Execuções Criminais. Após, deverá a z. Serventia lançar a movimentação "Cód. 62050 - Autos no Prazo - Execução da Multa Penal". I. Comunicado pelo Juízo da Execução o ajuizamento da ação de execução da multa penal, deverá a z. Serventia proceder à anotação no histórico de partes do evento "Cód. 17 - Início da Execução da Pena de Multa", indicando no complemento o número do processo de execução e lançando a movimentação "Cód. 61619 - Definitivo - Processo Findo com Condenação", arquivando-se a seguir. II. Não havendo comunicação pelo Juízo da Execução o ajuizamento da ação de execução da multa penal, aguarde-se o transcurso do lapso prescricional. Após, volvam-me os autos conclusos para declaração da extinção da pena.

V.VI. DETERMINO a incineração das substâncias entorpecentes apreendidas (Lei nº 11.343/06, art. 72), caso a providência já não tenha sido adotada.

V.VII. Oficie-se ao INI, ao IIRGD, à VEC e ao TRE (art. 398, II, das NSCGJ).

V.VIII. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se.

Paranapanema, 14 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA